연구논문

비법인사단의 법인전환과 취득세 과세요건

– 조세법률주의와 입법적 정비의 관점에서: 부산고등법원 2023. 11. 24. 선고 2023누22276 판결을 중심으로 –

박상영*·김민규**

비법인사단이 주무관청의 인가와 설립등기를 거쳐 사단법인으로 전환한 뒤, 종전 비법인사단이 보유하던 부동산을 사단법인 명의로 이전등기하는 경우, 그 이전등기가 지방세법상 취득세 과세요건으로서의 '취득'에 해당하는지 여부는 단순한 세무실무 차원을 넘어 헌법상 재산권과 조세법률주의에 직결되는 쟁점이다. 부산고등법원 2023. 11. 24. 선고 2023누22276 판결은 취득세의 유통세적 성격, 총유에서 법인 단독소유로의 형식적 전환, 감면규정 부재를 근거로 과세를 긍정한 반면, 서울행정법원 2005. 2. 15. 선고 2004구합17839 판결은 전환 전후 단체의 실질적 동일성이 유지되는 경우 새로운 취득을 부정하였다. 두 판결은 유사한 구조의 사안에서 동일한 '취득' 개념을 적용하면서도 형식과 실질, 단체 동일성에 대한 평가 기준을 달리함으로써 상반된 결론에 이르고 있다.

본고는 먼저 부산고등법원 판결의 논증 구조를 유통세 일반론의 원용, 권리주체 변경의 인정, 감면규정 부재 확인이라는 세 단계로 재구성한 뒤, 조세법률주의·과세요건명확주의, 차용개념론, 비법인사단 재산의 총유 구조에 비추어 각 단계의 방법론적 정합성을 검토한다. 그 과정에서 취득세의 유통세적 성격 자체를 부정하기보다는, 전형적 매매·증여와 구별되는 조직변경 사안에 유통세 일반론을 적용할 때 요구되는 추가적인 실질 검토와 단체 동일성 판단이 대상판결에서는 충분히 이루어지지 않았음을 지적한다. 이어 지방세법상 '취득' 개념과 비법인사단의 법인전환 법리가 만나는 지점을 중심으로, 실질적 권리귀속 주체의 교체 여부를 기준으로 과세와 비과세를 구분하는 잠정적 해석론을 제시한다.

그러나 해석론만으로는 동일 유형 사안에 대한 하급심 판결의 상반된 결론과 납세자의 예측가능성 부족 문제를 근본적으로 해소하기 어렵다. 이에 본 논문은 비법인사단이 실질적 동일성을 유지한 채 사단법인으로 전환하는 과정에서 이루어지는 재산 이전에 관하여, 지방세법상 '취득' 규정에 조직변경에 대한 예외를 명시하거나 별도의 비과세·감면 규정을 두는 등 입법적 정비가 필요하다는 점을 제안한다. 비교법적으로는 독일 조직변경법(UmwG)과 부동산취득세법(GrEStG)의 관련 규율을 참조하여, 조직법상 동일성과 조세법상 과세요건·비과세요건의 연계를 통하여 해석상 불확실성을 줄이는 입법 모델을 검토한다. 결국 비법인사단의 법인전환에 따른 부동산 이전등기는 전환 전후 단체의 실질적 동일성이 유지되는 한 지방세법상 '취득'으로 보지 않는 것이 조세법률주의와 체계정합성에 부합하며, 이를 명시하는 입법적 정비를 통하여 현행 해석상 혼란과 과잉과세 위험을 완화할 필요가 있다.

주제어: 비법인사단, 사단법인, 법인전환, 취득세, 총유, 조세법률주의, 유추해석금지, 실질과세, 차용개념론, 형태전환

* 석사과정생(서울대학교 대학원 법학과)
** 변호사, 겸직교수(KAIST 문술미래전략대학원)

목 차

Ⅰ. 서론: 문제의 제기와 연구의 목적
1. 연구의 목적: 문제 제기
2. 논의의 집중: 해석론과 입법에 관하여
3. 본고의 목적과 연구 방법

Ⅱ. 대상판결의 개요: 부산고등법원 2023누22276
1. 사실관계
2. 적용 법조
3. 판결의 요지: 3단계 논증 구조
4. 쟁점의 위치

Ⅲ. 관련 판례·법리의 요지
1. 취득세의 법적 성격: 유통세설, 권리변동세설, '사실상 취득'
2. 차용개념론과 취득 개념 해석
3. 비법인사단, 총유, 권리주체 동일성: 학설과 판례
4. 과세요건과 면세규정의 관계, 그리고 petitio principii

Ⅳ. 대상 판결의 논증 구조와 비판
1. 부산고등법원 2023. 11. 24. 선고 2023누22276 판결 논리의 구조와 한계
2. 서울행정법원 2005. 2. 15. 선고 2004구합17839 판결의 시사점과 보완 과제
3. 조세법 해석방법론의 관점에서 본 두 판결의 위치

Ⅴ. 결론
1. 요약
2. 입법론으로의 지향

Ⅰ. 서론: 문제의 제기와 연구의 목적

1. 연구의 목적: 문제 제기

비법인사단이 주무관청의 인가와 설립등기를 거쳐 사단법인으로 전환한 뒤, 종전 비법인사단 명의로 보유하던 부동산을 사단법인 명의로 이전등기하는 경우, 그 이전등기가 지방세법상 취득세 과세요건으로서의 '취득'에 해당하는지 여부는 이론·실무 양면에서 반복적으로 제기되는 쟁점이다.[1] 이 물음은 외견상 개별 세목의 과세요건 해당 여부에 관한 실무적 쟁점으로 보일 수 있으나, 비법인사단의 조직변경과 지방세법상 '취득' 개념, 그리고 조세법률주의가 교차하는 지점이라는 점에서 법이론적 쟁점일 뿐 아니라, 현행 규범 구조의 한계를 전제로 입법적 정비 필요성을 검토하는 법제연구의 대상이 되기도 한다.[2]

부산고등법원 2023. 11. 24. 선고 2023누22276 판결(이하 '대상판결')은, 비법인사단 재산의 총유 구조, 취득세의 유통세적 성격, 감면규정의 부재를 근거로, 비법인사단에서 사단법인으로의 전환에 수반된 부동산 이전을 취득세 과세대상 '취득'으로 보아 과세를 긍정하였다. 반면 서울행정법원 2005. 2. 15. 선고 2004구합17839 판결은, 전환 전후 단체의 실질적 동일성이 유지되는 경우에는 새로운 취득이 없다고 보아 과세를 부정한 바 있다.[3] 양 판결은 유사한 사실구조와 동일한 취득세 규정을 전제로 하면서도, 권리주체의 동일성과 형식적 명의 변경의 의미를 달리

1) 이 물음은 특히 지역 종교단체, 동창회, 향우회, 직능단체 등 다수의 비법인사단이 법인화를 추진하는 과정에서 실무적으로 반복 제기되어 왔다. 이혜진, "판례에 나타난 비법인사단의 유형 및 규율에 관한 입법론", 동아법학 제71호, 동아대학교 법학연구소, 2016, 29-31쪽; 문필주, "실질과세원칙 적용시 납세자 유·불리에 관한 판례의 현황과 그 분석", 세무학연구 제35권 제3호, 한국세무학회, 2018, 90-114쪽; 윤문구·문필주·박훈, "조세심판원 심판례 분석을 통한 취득세 취득개념의 해석론 및 입법론", 경희법학 제55권 제1호, 경희대학교 법학연구소, 2020, 102-103쪽.

2) 이창희, 세법강의, 박영사, 2024, 47-52쪽; 임승순, 조세법, 박영사, 2024, 119-131쪽. 조세법률주의의 헌법적 근거와 내용에 관하여는 허완중, "조세법률원칙(조세법률주의)에 관한 헌법적 검토", 법학연구 통권 제75집, 전북대학교 법학연구소, 2024, 77-81쪽; 김영순, "조세법률주의의 현대적 의미에 대한 소고—납세자의 예측가능성 보장 관점에서—", 법학논총 제31권 제1호, 한양대학교 법학연구소, 2014, 545-567쪽; 김성욱, "민법상 사단(社團)과 관련한 법적 문제", 법학논총 제21권 제1호, 조선대학교 법학연구원, 2014, 267-287쪽.

3) 부산고등법원 2023. 11. 24. 선고 2023누22276 판결(확정). 이 판결은 제1심인 부산지방법원 2023. 7. 7. 선고 2023구합21656 판결에 대한 항소심 판결로서 확정되었다. 한편 서울행정법원 2005. 2. 15. 선고 2004구합17839 판결은 비법인단체의 법인 전환 과정에서 이루어진 명의정리 증여를 취득으로 보기 어렵다고 판단한 사례이다(후술 Ⅲ.1. 참조).

평가함으로써 상반된 결론에 이르고 있다.

이 판결은 전환 전후 단체의 인적·물적 기반이 실질적으로 동일하게 유지되는 경우, 법인격 취득이라는 형식적 변화만으로 새로운 취득이 발생하였다고 볼 수 없다는 입장을 취한다.

2. 논의의 집중: 해석론과 입법에 관하여

조세법률주의와 과세요건 해석에 관해서는 헌법재판소와 대법원 판례, 그리고 다수의 이론 연구에서 그 내용과 한계가 논의되어 왔다.[4] 헌법재판소 2012. 5. 31. 선고 2009헌바123·126(병합) 결정은 전부개정으로 실효된 조세감면규제법 부칙 조항을 계속 과세요건으로 해석한 대법원 판례를 조세법률주의와 권력분립 원칙 위반으로 보아 한정위헌을 선언함으로써, 실효된 규범을 다시 과세요건으로 인정하는 해석은 존재하지 않는 과세요건을 창설하는 것과 다름없다는 점을 명확히 하였다. 이 결정은 과세요건법정주의·과세요건명확주의의 헌법적 위상을 재확인한 것으로 평가된다.

한편 형법 영역에서는 죄형법정주의와 유추해석금지에 관한 심도 깊은 논의가 축적되어 왔으며, 법문언의 가능한 의미(möglicher Wortsinn) 기준이 해석과 유추의 경계를 실질적으로 구분하는 기준이 되기 어렵다는 비판도 제기되어 왔다.[5] 형법학계에서는 법관의 법형성 행위가 이 기준을 통해 사후적으로 정당화되는 위험을 지적하면서, 법해석과 법형성의 한계를 보다 엄격히 설정할 것을 요구한다.[6] 이러한

4) 조세법률주의와 과세요건 해석의 한계에 관하여는 대법원 2004. 5. 28. 선고 2003두7392 판결; 헌법재판소 1992. 2. 25. 선고 90헌가69 결정(병합) 참조. 학설로는 이창희, 앞의 책, 47-62쪽; 임승순, 앞의 책, 119-131쪽; 김상훈, "무상취득 관련 취득세 쟁점", 지방세논집 제7권 제3호, 한국지방세학회, 2020, 331-355쪽; 황헌순, "헌법상 조세의 기본원칙과 세법상 실질과세", 유럽헌법연구 제36호, 유럽헌법학회, 2021, 388-414쪽.

5) 죄형법정주의와 유추해석금지에 관한 국내 논의로는 김성룡, "유추의 구조와 유추금지", 법철학연구 제12권 제2호, 한국법철학회, 2009, 35-78쪽.

6) 법관의 법형성 행위가 '문언의 가능한 의미'라는 기준을 통해 사후적으로 정당화되는 구조에 대한 비판적 검토로는 오세혁, "법해석방법의 우선순위에 대한 시론적 고찰", 중앙법학 제21집 제4호, 중앙법학회, 2019, 385-427쪽; 김영환, "한국에서의 법학방법론의 문제점—법발견과 법형성: 확장해석과 유추, 축소해석과 목적론적 축소 간의 관계를 중심으로—", 법철학연구 제18권 제2호, 한국법철학회, 2015, 137-138쪽; 이계일, "우리 법원의 법률해석/법형성에 대한 반성적 고찰", 법학연구 제25권 제4호, 연세대학교 법학연구원, 2015, 310-338쪽.

논의는 조세법 영역의 유추해석금지·조세법률주의 논의와 구조적 유사성을 가지며, 과세요건 해석의 한계를 설정하는 데 참고가 될 수 있다.

그럼에도 비법인사단의 법인전환에 따른 취득세 과세 문제를 직접 대상으로 삼아 위 두 판결의 논증 구조와 법리를 체계적으로 분석한 학술 연구는 현재까지 확인되지 않는다.[7] 취득세의 법적 성격(유통세설·권리변동세설)과 지방세법상 차용개념('취득', '증여' 등)의 해석에 관해서는 세법 문헌과 논문에서 활발히 논의되어 왔으나, 이를 비법인사단의 민법상 지위 및 법인전환 법리와 결합하여 과세요건 해석의 한계와 연결한 연구는 부재하다.[8] 나아가 형법상 죄형법정주의·유추해석금지 논의와 조세법상의 유추해석금지 논의를 방법론적으로 연계하여, 두 영역이 공유하는 법률주의 원칙과 해석상 긴장을 구조적으로 분석한 연구도 드물다.[9] 이러한 상황에서 해소되어야 할 물음은 다음과 같다.

첫째, 지방세법상 취득세 규정에서 사용하는 '취득' 개념은, 비법인사단의 법인전환과 같이 조직법상 동일성이 문제되는 사안에도 전형적 유상·무상 거래와 동일한 방식으로 적용될 수 있는가. 둘째, 비법인사단 재산의 총유 구조와 단체의 조직적 동일성을 고려할 때, 비법인사단에서 사단법인으로의 전환에 수반된 부동산 이전을 새로운 권리취득으로 볼 수 있는 기준은 어디에 설정되어야 하는가. 셋째, 해석론만으로는 동일 유형 사건에 대한 하급심 재판실무의 불일치와 납세자의 예측가능성 부족을 어느 정도까지 해결할 수 있으며, 그 한계를 보완하기 위한 입법적 정비의 방향은 무엇인가.

이 글은 위 물음들에 대하여, (1) 전환 전후 단체의 실질적 동일성이 유지되는 한, 비법인사단에서 사단법인으로의 전환에 수반된 부동산 이전을 지방세법상 '취득'으

7) 국내 데이터베이스(KISS, KCI, DBpia, RISS)를 통하여 '비법인사단', '법인전환', '취득세'를 결합한 검색어로 관련 논문을 검색한 결과, 이 주제를 직접 다룬 학술 논문은 확인되지 않았다(2026년 3월 검색 기준).

8) 취득세의 법적 성격과 지방세법상 차용개념의 해석에 관한 기존 연구로는 권형기, "지방세법상 취득과 조세법상 차용개념에 대한 소고", 조세와 법 제6권 제2호, 서울시립대학교 법학연구소, 2013, 87-118쪽; 이중교, "주택재개발사업과 재건축사업의 취득세 과세에 대한 연구", 공법연구 제37집 제1호, 한국공법학회, 2008, 361-385쪽. 비법인사단의 민법상 지위에 관하여는 곽윤직/김재형, 민법총칙, 박영사, 2013, 154-162쪽; 신만중, "취득의 개념과 부동산명의신탁", 법학연구 제25권 제3호, 충남대학교 법학연구원, 2014, 293-313쪽.

9) 조세법에서의 유추해석금지와 법관법의 한계에 관하여는 이재호, "세법상 유추의 可否에 관하여", 조세법연구 제17집 제1호, 한국세법학회, 2011, 121-175쪽; 최봉경, "민법에서의 유추와 해석—판례를 거울삼아—", 법철학연구 제12권 제2호, 한국법철학회, 2009, 135-158쪽.

로 보아 과세할 수 없으며, (2) 이러한 해석론을 전제하되, 동일 유형 사건에 관한 해석상 불확실성과 과잉과세 위험을 줄이기 위하여 조직변경에 관한 비과세·면제 규정을 명시하는 입법적 정비가 필요하다는 점을 주장하고자 한다.

3. 본고의 목적과 연구 방법

이를 위하여 먼저 Ⅱ장에서는 대상판결의 사실관계와 판시 이유를 정리하여, 취득세의 유통세론, 비법인사단 재산의 권리귀속 구조, 감면규정 부재에 관한 대상판결의 논증 구조를 세 단계의 논리로 재구성한다. Ⅲ장에서는 동일 유형 사안을 다룬 서울행정법원 2004구합17839 판결 및 관련 대법원 판례, 비법인사단 재산의 총유와 단체 동일성에 관한 민법·조세법 학설을 검토하여, 대상판결의 논리가 선행 판례·법리에 비추어 어떤 위치에 놓이는지를 살핀다. Ⅳ장에서는 조세법률주의 및 과세요건명확주의, 차용개념론에 입각하여 대상판결의 각 논증 단계(유통세론의 원용, 권리주체 변경 인정, 면세규정 부재)의 정합성을 비판적으로 검토하고, 전환 전후 단체의 실질적 동일성 및 실질적 권리귀속 주체의 교체 여부를 기준으로 과세·비과세를 구분하는 해석론을 제시한다. 끝으로 Ⅴ장에서는 이러한 해석론의 한계를 전제한 상태에서, 조직변경에 수반된 부동산 이전에 관하여 '취득' 개념의 적용범위를 명시적으로 한정하거나 별도의 비과세·면제 규정을 두는 방향의 입법적 개선 방안을 제안한다. 그 과정에서 국내외 조직변경 및 부동산 취득세 입법례, 특히 독일 조직변경법(UmwG)과 부동산취득세법(GrEStG)이 조직법상 동일성과 추디ㄴ세 과세요건을 연계하는 방식을 참조한다.

Ⅱ. 대상판결의 개요: 부산고등법원 2023. 11. 24. 선고 2023누22276 판결

1. 사실관계

이 사건에서 비법인사단인 A 단체는 특정 부동산을 취득하여 보유하고 있었고,

이후 주무관청의 인가와 설립등기를 거쳐 사단법인으로 전환하였다.[10] 사단법인은 종전 비법인사단이 보유하던 이 사건 각 부동산에 관하여 증여를 원인으로 소유권이전등기를 경료하였고, 과세관청은 이를 지방세법 제7조의 '취득'에 해당한다고 보아 사단법인에게 취득세를 부과하는 처분을 하였다. 사단법인은 전환 전후 단체의 인적·물적 동일성을 주장하면서, 이는 소유권의 실질적 이전이 아니라 법인격 취득에 따른 형식적 명의정리에 불과하므로 취득세 과세대상이 아니라고 다투었다.

제1심인 부산지방법원 2023. 7. 7. 선고 2023구합21656 판결은 과세관청의 처분을 적법하다고 보았고, 항소심인 부산고등법원도 이를 유지하여 판결은 확정되었다.[11] 제1심은 지방세법 제6조 제1호의 '취득' 정의 규정을 직접 적용하여, 원고가 A 단체로부터 이 사건 각 부동산에 관하여 소유권이전등기를 마친 것은 지방세법 제6조 제1호의 취득에 해당한다고 보았다. 반면 항소심은 지방세법 제7조 제1항의 납세의무 규정과 제2항의 '사실상 취득' 규정을 적용하여, 증여계약을 체결한 것은 지방세법 제7조 제2항에서 규정한 사실상 취득에 해당한다고 판단하였다. 동일한 사실관계 하에서 심급 간 적용 법조가 달라졌다는 점은, '취득'이라는 법개념의 의미 범위가 해석자의 관점에 따라 달리 구성될 수 있음을 시사한다.

제1심은 또한 A 단체의 규약과 사단법인의 정관을 비교하여 임원 구성, 기본재산 관리, 해산 규율 등에서 '실질적인 차이점이 존재'한다고 판시하였다.[12] 항소심은 이러한 규약·정관 비교 논증을 판결 이유에서 삭제하고, 취득세의 법적 성격과 소유형태의 차이에 기초한 보다 추상적·법리적 논증 구조로 전환하였다. 이는 항소심이 1심의 규약·정관 비교 논증이 사단성의 본질적 요소와 부수적 형식 사이를 충분히 구별하지 못한 채 병렬적으로 나열하는 데 그쳤다고 보고, 그 논증력을 제한적으로 평가한 것으로 이해할 수 있다.

---

10) 비법인사단 A 단체의 구체적인 명칭과 성격은 판결문의 공개 범위 내에서 확인되는 내용에 한정하였다. 이 사건 사실관계는 부산고등법원 2023누22276 판결 이유 제1항 및 부산지방법원 2023구합21656 판결 이유 제1항을 토대로 재구성하였다.

11) 부산지방법원 2023. 7. 7. 선고 2023구합21656 판결; 부산고등법원 2023. 11. 24. 선고 2023누22276 판결. 제1심은 지방세법 제6조 제1호의 '취득' 정의 규정을 중심으로 적용하였고, 항소심은 제7조 제2항의 '사실상 취득' 규정을 중심 법조로 삼아 적용하였다.

12) 부산지방법원 2023구합21656 판결 이유 제3항. 사단성의 본질적 요소와 부수적 형식의 구별에 관하여는 곽윤직/김재형, 앞의 책, 170-175쪽. 항소심은 1심의 규약·정관 비교 논증을 생략하고, 취득세의 법적 성격과 소유형태의 차이에 기초한 법리적 논증으로 전환하였다(부산고등법원 2023누22276 판결 이유 제3항 내지 제5항).

2. 적용 법조

부산고등법원은 이 사건에 관하여 지방세법 제7조 제1항·제2항을 적용하였다. 동조 제1항은 부동산 등의 취득에 대하여 취득세를 부과하는 기본 규정을 두고 있으며, 제2항은 '등기·등록을 이행하지 아니한 경우라도 사실상으로 취득하면 각 취득일에 취득한 것으로 본다'고 규정한다. 한편 지방세법 제6조 제1호는 '취득'을 매매, 교환, 상속, 증여, 기부, 현물출자 등 일정한 원인에 의한 소유권 취득으로 정의하면서, '그 밖에 이와 유사한 취득'을 포함시키는 포괄 규정을 두고 있다. 이 사건에서 항소심은 제6조 제1호의 정의 규정보다는 제7조 제2항의 '사실상 취득' 개념을 중심으로 과세요건 충족 여부를 검토하였다는 점에서 제1심과 구별된다.

부산고등법원은 판결에서 취득세의 법적 성격에 관한 대법원 판례를 인용하면서, 부동산취득세는 재화의 이전이라는 사실 자체를 포착하여 거기에 담세력을 인정하고 부과하는 유통세의 일종이라는 점을 전제로 삼았다.[13]

3. 판결의 요지: 3단계 논증 구조

부산고등법원은 취득세의 유통세적 성격, 권리주체 변경의 인정, 감면규정 부재라는 세 단계의 논리를 순차적으로 전개하여 과세를 정당화하였다.

첫째, 법원은 취득세가 부동산 등의 취득이라는 사실 자체를 포착하여 담세력을 인정하는 유통세라는 점을 전제로 하였다. 즉, 취득세는 실질적인 경제적 이득의 유무와 무관하게 재산권의 이전이라는 유통 사실 그 자체에 조세부담을 연결하는 조세로 이해된다고 보았다. 대상판결은 이와 같은 유통세 일반론을 전제로, 비법인사단에서 사단법인으로의 전환에 수반된 부동산 이전도 일단 "재산의 유통"에 해당한다고 파악하였다.

둘째, 법원은 비법인사단 재산이 구성원들의 총유에서 사단법인 명의의 단독소유로 전환되었다는 점에 착목하여, 권리주체가 변경되었다고 보았다. 비법인사단의 재

13) 대법원 1984. 11. 27. 선고 84누52 판결; 대법원 2002. 6. 28. 선고 2000두7896 판결; 대법원 2017. 6. 8. 선고 2014두43554 판결. 인용된 판시는 대법원 2014두43554 판결에서의 표현에 기초하였다.

산은 구성원 전원의 총유에 속하고, 사단법인의 재산은 법인 자체의 고유재산이라는 점에 비추어, 비법인사단에서 사단법인으로의 전환과 그에 따른 이전등기는 재산의 귀속 주체가 "구성원들의 집합체"에서 "별도의 법인격을 가진 사단법인"으로 변경되는 것으로 평가된다고 본 것이다. 대상판결은 이러한 권리주체 변경의 인식을 전제로, 부동산 소유권의 실질적 취득이 이루어졌다고 판단하였다.

셋째, 법원은 지방세법상 비법인사단의 법인전환에 수반된 부동산 이전을 취득세 과세대상에서 제외하거나 감면하는 명시적 규정이 존재하지 않는다는 점을 확인하였다. 입법자가 다른 유형의 조직변경·합병 등에 대하여는 특별한 비과세·감면 규정을 두면서도, 비법인사단에서 사단법인으로의 전환에 대하여는 그러한 규정을 두지 않았다는 사정을 고려하여, 해당 유형의 이전에 대해서는 일반적인 취득세 과세요건이 그대로 적용된다고 보았다. 대상판결은 이와 같이 감면규정의 부재를 이유로, 전환에 수반된 이전등기를 취득세 과세대상에서 제외할 근거가 없다고 결론지었다.

이상의 세 가지 요소를 종합하여, 부산고등법원은 비법인사단이 사단법인으로 전환한 후 그 명의로 부동산 소유권이전등기를 한 경우, 지방세법상 취득세 과세요건으로서의 '취득'이 성립한다고 보고 과세처분을 적법하다고 판단하였다. 다시 말해, 대상판결은 유통세 일반론 → 권리주체 변경 → 감면규정 부재라는 단계를 거쳐, 전환 전후 단체의 실질적 동일성이 유지되는 사안에서도 취득세 과세를 인정하는 해석론을 제시한 것으로 이해할 수 있다.

4. 쟁점의 위치

이 판결은 비법인사단의 법인전환에 따른 부동산 이전을 취득세 과세요건인 '취득'에 포함시킨 최초의 고등법원 확정판결이라는 점에서, 이후 유사 사안에서의 실무적 기준점으로 기능할 가능성이 크다. 동시에, 취득세의 유통세적 성격을 강조하여 형식적 외관만으로 과세요건을 충족시키는 논리를 취함으로써, 조세법률주의가 요구하는 과세요건의 엄격 해석·유추해석금지 원칙과 긴장을 형성한다고 볼 여지가 있다. 특히 총유와 법인 단독소유의 법기술적 구별을 곧바로 권리주체의 변경으로 연결하는 논리, 그리고 감면규정 부재를 과세의 긍정 근거로 원용하는 논리는, 취득

세의 법적 성격과 조세법률주의의 관계, 세법상 차용개념 해석론 측면에서 검토를 요하는 쟁점을 제기한다.

Ⅲ. 관련 판례·법리의 요지

1. 취득세의 법적 성격: 유통세설, 권리변동세설, '사실상 취득'

지방세법상 취득세의 법적 성격에 관해서는 전통적으로 유통세설(형식설)과 권리변동세설(재산세설·실질설)의 대립이 존재한다.[14] 유통세설은 취득세가 부동산 등의 취득이라는 사실 자체, 즉 재화의 이전이라는 경제적 유통 행위를 포착하여 담세력을 인정하는 세목이라고 보고, 이에 따라 실질적인 권리 귀속이나 완전한 소유권 취득 여부와 무관하게 소유권 이전의 외관이 존재하는 한 취득세 납세의무가 성립한다는 형식적 논리와 연결된다.[15] 반대로 권리변동세설은 취득세가 부동산에 관한 권리의 실질적 변동, 다시 말해 종전 권리주체로부터 새로운 권리주체에게 실질적인 지배권이 이전되는 사실을 과세근거로 삼는 세목이라고 이해하여, 과세요건 판단에서 실질적인 권리귀속을 보다 중시한다.

대법원은 1984년 이래 반복적으로 취득세를 '재화의 이전이라는 사실 자체를 포착하여 담세력을 인정하는 유통세'라고 규정해 왔고, 학계와 실무는 이를 취득세의 유통세적 성격을 확인한 것으로 이해해 왔다.[16] 그러나 이러한 유통세론이 어떠한 사안에서나 자명하게 적용될 수 있는 만능 기준인지에 대해서는 학설상 상당한 이견이 있다. 취득세가 유통세라는 점은 전형적인 매매·증여·교환 등 서로 독립된 권리주체 사이에서 재화가 이전되는 경우를 전제로 형성된 것이며, 조직변경과 같이

14) 취득세의 법적 성격에 관한 학설 개관은 이창희, 앞의 책, 883-888쪽; 임승순, 앞의 책, 702-706쪽

15) 유통세설의 논거로서는 취득세의 과세표준이 취득가액이라는 점, 거래 사실 발생 시점에 납세의무가 성립한다는 점 등이 제시된다. 권리변동세설에 의하면 취득세는 부동산에 관한 실질적 지배권의 이전 사실에 과세하는 것이므로, 실질적 권리변동이 없는 형식적 명의 변경은 원칙적으로 과세대상이 될 수 없다. 임승순, 앞의 책, 704-705쪽.

16) 대법원 1984. 11. 27. 선고 84누52 판결; 대법원 2002. 6. 28. 선고 2000두7896 판결; 대법원 2017. 6. 8. 선고 2014두43554 판결. 대법원은 이 판결들에서 일관되게 '부동산취득세는 재화의 이전이라는 사실 자체를 포착하여 거기에 담세력을 인정하고 부과하는 유통세의 일종'이라는 법리를 유지하고 있다.

권리주체의 동일성 자체가 문제되는 사안에 동일한 강도로 적용될 것인지에 대해서는 별도의 검토가 필요하다.[17]

이 점을 특히 잘 보여 주는 것이 지방세법 제7조 제2항의 '사실상 취득' 규정이다. 동 조항은 "등기·등록을 하지 아니한 경우에도 사실상 취득한 때에는 취득한 것으로 본다"고 규정하여, 형식적 등기·등록이 없더라도 사실상의 취득이 있으면 과세요건을 인정하도록 하고 있다.[18] 형식(등기·등록)과 무관하게 경제적 유통 사실이 존재하면 과세한다는 취지를 강화하는 규정으로 볼 수 있지만, 동시에 형식적 요건만으로는 부족하고 실질적인 지배권 이전이라는 내용상의 요건이 충족되어야 한다는 실질설의 요소를 내포한 규정으로도 해석될 수 있다. 결국 취득세의 법적 성격은 유통세설 하나로 일의적으로 귀결되기보다, 형식과 실질 사이의 긴장 속에서 개별 사안의 특성에 따라 어느 요소를 더 강조할지 선택을 요구하는 구조를 갖는다.

이러한 맥락에서 보면, 대상판결이 취득세의 유통세적 성격을 전제로 비법인사단에서 사단법인으로의 전환에 수반된 부동산 이전을 "재화의 유통"으로 곧바로 파악한 것은, 유통세론을 전형적 사안에서 이 사건과 같은 조직변경 사안으로 그대로 연장한 해석으로 이해된다. 그러나 조세법률주의 및 과세요건명확주의의 관점에서 과세요건으로서의 '취득' 개념은 지방세법 제6조 제1호가 정한 문언의 가능한 의미 범위 안에서 그 체계와 입법취지를 고려하여 해석되어야 한다. 이때 본고가 취하는 해석은 과세의 범위를 넓히는 것이 아니라 오히려 한정하는 방향의 해석으로서, 법률에 없는 과세요건을 새로 만들어 내는 법형성과 구별되고 납세자에게 불리한 확장해석에도 해당하지 아니한다. 따라서 선행 판례의 일반 명제를 기계적으로 수용하기 이전에, 해당 사안에서 과세요건의 성립을 정당화하는 실질적 담세력이 존재하는지를 독립적으로 심사하여야 한다. 나아가 대법원 2018. 3. 22. 선고 2014두

17) 취득세의 유통세적 성격을 강조하는 논의는 궁극적으로 재화의 이전이라는 외관을 통하여 담세력의 발생을 포착하려는 데 그 이론적 근거를 둔다. 그러나 비법인사단의 법인전환과 같이 동일한 단체가 전환 전후에 걸쳐 부동산을 계속 지배·사용하며, 구성원 구성과 목적 사업, 자산·부채 구조에 본질적인 변화가 없는 사안에서는, 소유권 명의의 변경이 반드시 새로운 경제적 이익의 실현이나 담세력의 증가를 의미하지 않는다. 요컨대 유통세설이 취득세의 법적 성격을 설명하는 유용한 틀임은 부인할 수 없으나, 그 타당성은 어디까지나 재산의 이전이 새로운 담세력의 발생과 결부되는 전형적 사안을 전제로 한다.

18) 취득세의 법적 성격에 관한 이원론적 이해, 즉 '유통세이면서도 일정한 실질적 요건을 요구하는 세목'이라는 관점에 관하여는 최원, "취득세의 법적 성질론에 관한 소고—부동산에 대한 취득세를 중심으로—", 세무학연구 제37권 제4호, 한국세무학회, 2020, 187-213쪽.

43110 전원합의체 판결은 매매대금을 모두 지급하여 부동산을 사실상 취득한 자가 그 후 자기 명의로 소유권이전등기를 마치더라도 이는 형식적 요건을 추가로 갖춘 것에 불과하여 별도의 취득세 납세의무가 성립하지 않는다고 보아, 소유권이전등기라는 형식만으로 언제나 새로운 취득세 과세요건이 충족되는 것은 아님을 분명히 하였다. 또한 실질과세의 원칙이 지방세에도 준용되는 점을 고려하면, 유통세론이 실질에 대한 검토를 전적으로 배제하는 개념이라고 볼 수는 없다.[19]

요컨대, 취득세의 유통세론은 전형적인 거래 구조에서 재산의 이전이라는 사실 자체에 조세를 부과한다는 점에서는 공통된 출발점을 제공하지만, 비법인사단의 법인전환과 같이 권리주체의 동일성이 문제되는 사안에 그대로 적용되기 위해서는 별도의 실질적 검토가 요구된다. 대상판결은 유통세 일반론을 전제로 전환에 따른 명의변경을 '유통'에 해당한다고 보았으나, 유통세설과 권리변동세설의 학설 대립, '사실상 취득' 규정의 존재, 그리고 일부 판례의 실질설적 요소를 종합적으로 고려할 때, 이러한 전제 설정은 조세법률주의가 요구하는 과세요건의 독립적 심사라는 관점에서 한계를 가진다.

2. 차용개념론과 취득 개념 해석

지방세법 제6조 제1호는 "취득"을 매매, 교환, 상속, 증여 등 일정한 원인에 의한 소유권 등의 취득으로 정의하면서, 민법 제554조의 증여 개념 등 민법상의 용어를 그대로 차용하고 있다. 이때 세법상 '차용개념론'은, 세법이 다른 법영역의 개념을 사용할 때 그 의미를 세법 고유의 목적에 따라 독자적으로 해석할 것인지(고유목적론), 아니면 법체계 전반에서 통일적으로 해석할 것인지(통일적 해석론)에 관한 방법

19) 대법원 2018. 3. 22. 선고 2014두43110 전원합의체 판결. 다만 이 판결은 매매대금 완납에 의한 '사실상 취득' 이후의 형식적 등기가 문제된 사안으로서, 비법인사단의 법인전환 사안과는 사실관계를 달리하므로 그 법리는 '형식적 등기만으로 언제나 새로운 취득세 과세요건이 충족되는 것은 아니다'라는 한도에서 원용한다. 한편 종래 대법원 2002. 6. 28. 선고 2000두7896 판결은 '취득세는 유통세로서 실질적으로 완전한 소유권을 취득하는지 여부와 관계없이 형식에 의한 모든 취득을 포함한다'는 취지로 형식설을 강하게 확인한 판결로서, 오히려 본고가 구별·극복하고자 하는 형식설 판례에 해당한다. 취득세의 유통세적 성격이 해석에 미치는 영향에 관한 평석으로 권형기·고영우. "취득세의 '유통세적 성격'이 해석에 미치는 영향: 대법원 2018. 3. 22. 선고 2014두43110 전원합의체 판결과 취득세의 소비세적 성격을 중심으로". 지방세논집 제9권 제1호, 한국지방세학회, 2022. 8-16쪽.

론적 논의이다.[20]

고유목적론은 세법이 과세대상을 포착하는 방식을 민법 등에 종속시키지 않고 세법 고유의 조세기능에 따라 독립적으로 구성해야 한다고 주장한다. 반면 통일적 해석론은 동일한 국가법체계 내에서 동일 개념이 상이한 의미를 갖게 되면 법적 안정성이 침해된다는 점을 들어, 세법도 가능하면 원래 법영역의 의미를 따르는 것이 바람직하다고 본다.[21]

비법인사단의 법인전환에 따른 부동산 이전에서 등기원인이 "증여"로 기재된 경우, 민법상 증여의 실질이 존재하는지 여부는 이러한 차용개념론의 선택과 결부된다. 민법상 증여는 일방 당사자가 무상으로 재산을 상대방에게 수여하는 계약을 의미하므로, 동일한 단체가 법인격을 취득하는 과정에서 단체 내부의 재산귀속 구조를 조정하는 행위를 곧바로 "증여"로 볼 것인지, 아니면 조직법적 재편의 일환으로 별도로 파악할 것인지는 논란의 여지가 있다. 대상판결은 등기원인으로서의 "증여" 기재를 별도의 검토 없이 과세요건 포섭의 근거로 원용하는 경향을 보이는데, 이는 차용개념론의 관점에서 세법 고유 목적에 따른 독자 해석 가능성을 충분히 검토하지 않은 것으로 평가될 수 있다.

요컨대, 취득세에서 '취득' 개념을 어떻게 해석할 것인지는 유통세설 대 권리변동세설의 학설 대립과 더불어, 세법이 민법 개념을 차용하는 방식에 관한 차용개념론의 선택과 불가분의 관련을 가진다. 비법인사단의 법인전환 사안에서 취득 개념을 해석하기 위해서는, 먼저 세법 고유의 과세요건 구조와 민법상의 거래유형 개념이 어떤 관계에 놓이는지를 명료하게 할 필요가 있다.

---

20) 세법상 차용개념에 대한 해석은 형법에서 논의된 유추해석금지 및 법문언의 가능한 의미(möglicher Wortsinn) 기준과 구조적으로 유사한 문제를 제기한다. 조세법에서 민법상의 증여·매매 등 개념을 차용하여 사용하는 경우에도, 세법의 목적을 이유로 그 의미를 납세자에게 불리한 방향으로 과도하게 확장하는 것은 조세법률주의가 요구하는 엄격해석 및 유추해석금지 원칙과 긴장을 형성할 수밖에 없다. 세법상 차용개념의 해석론 일반에 관하여는 김민호, "조세법에 있어 차용개념의 해석과 적용에 관한 연구 - 조세회피행위 방지와 관련하여-". 공법연구 제31권 제1호, 한국공법학회, 2002, 2-3쪽; 박훈, "판례에 나타난 세법상 차용개념의 해석론". 법조 제68권 제3호, 법조협회, 2019. 513-515쪽.

21) 세법 고유목적론(독자적 해석론)에 관하여는 이창희, 앞의 책, 63-64쪽; 통일적 해석론의 근거에 관하여는 임승순, 앞의 책, 122-123쪽.

3. 비법인사단, 총유, 권리주체 동일성: 학설과 판례

비법인사단은 다수의 구성원으로 이루어진 단체로서, 일정한 목적, 독자적인 규약, 의사결정기관과 집행기관의 존재, 구성원 변경에도 불구한 단체의 동일성 유지, 독자적인 재산의 존재 등 사단으로서의 실질적 요건을 갖추었으나 법인격을 취득하지 못한 단체를 말한다.[22] 대법원은 1999년 이후 비법인사단의 성립 요건으로 이른바 "사단성 요건"—단체로서의 조직, 다수결원칙, 구성원 변경에도 불구한 존속, 대표·총회·재산관리의 규범화—을 제시하면서, 비법인사단도 사단법인과 유사한 단체성을 가진다고 보아왔다.

비법인사단의 재산은 민법 제275조 이하에 따라 구성원 전원의 총유에 속한다고 규정된다. 총유의 법적 성질에 관해서는 공동소유설(합유설 유사설)과 단체적 귀속설(독립귀속설)이 대립한다. 공동소유설은 총유의 실질이 구성원 전원의 공동소유에 있다고 보고, 단체는 그 관리·처분 방식에만 영향을 줄 뿐 권리 귀속 주체는 여전히 구성원들의 집합이라고 본다. 반면 단체적 귀속설은 총유의 실질 주체가 구성원 개인이 아니라 단체 자체이며, 구성원의 지분은 관념되지 않고 총유물에 대한 관리·처분권은 단체의 의사결정기관에 귀속된다고 본다.

대법원은 총유를 공유·합유와 구별되는 독자적 소유 형태로 파악하면서, 구성원 각자의 지분이 관념되지 않고, 총유물의 관리·처분이 사원총회 결의에 의하여야 한다는 점을 반복적으로 강조해 왔다.[23] 이는 총유를 곧바로 "구성원 개개인의 공동소유"로 보는 공동소유설보다, 실질적인 귀속 주체를 "단체"로 파악하는 단체적 귀속

22) 비법인사단의 개념과 성립 요건에 관하여는 곽윤직/김재형, 앞의 책, 198-205쪽. 대법원 1999. 4. 23. 선고 99다4504 판결: '비법인사단이 되기 위해서는 사단으로서 실질, 즉 단체로서의 조직을 갖추고 있으며, 다수결의 원칙이 행하여지고, 구성원의 변경에도 불구하고 단체 그 자체가 존속되며, 그 조직에 의하여 대표의 방법, 총회나 이사회 등의 운영, 재산의 관리 기타 단체로서의 주요 사항이 확정되어 있어야 한다.'

23) 민법 제275조: '법인이 아닌 사단의 사원이 집합체로서 물건을 소유할 때에는 총유로 한다.' 제276조: '총유물의 관리 및 처분은 사원총회의 결의에 의한다.' 곽윤직/김재형, 앞의 책, 204-205쪽; 총유의 법적 성질에 관한 학설 대립에 관하여는 임상혁, "법인이 아닌 사단의 민사법상 지위에 관한 고찰—총유 규정을 둘러싼 민법 개정 논의와 관련하여—", 서울대학교 법학 제54권 제3호, 서울대학교 법학연구소, 2013, 189-209쪽; 진상욱, "비법인사단의 총유물의 관리 및 처분", 토지법학 제25권 제1호, 한국토지법학회, 2009, 75-88쪽; 최민수·박주영, "법인 아닌 사단과 총유규정에 관한 비판적 고찰—총유규정의 민법 개정안을 중심으로—", 법학논총 제45권 제1호, 단국대학교 법학연구소, 2021, 227-258쪽.

설과 친화적인 요소를 포함한다는 평가가 가능하다.[24] 이러한 관점에서 보면, 비법인사단 단계에서도 실질적 권리 귀속 주체는 이미 '단체'라고 볼 수 있고, 사단법인으로 전환한 뒤에도 그 단체가 권리 귀속 주체라는 점에서 실질적 변화가 없으며, 법인격 취득은 단지 법적 외형의 변화에 불과하다는 해석이 가능하다.[25]

서울행정법원 2004구합17839 판결은 비법인사단에서 재단법인으로의 전환 과정에서 이루어진 부동산 이전등기에 대해, 전환 전후 단체의 실질적 동일성이 유지되는 한 새로운 권리취득을 인정할 수 없다고 보아 취득세 부과를 취소하였다. 이 판결은 총유의 법적 성질과 사단성 요건의 연속성에 착목하여, 실질적 권리주체가 변하지 않았다는 이유로 권리주체 변경을 부정하는 입장에 서 있다. 반면 대상판결은 총유에서 법인 단독소유로의 귀속 구조 차이를 들어 권리주체 변경을 곧바로 인정하는데, 이는 사실상 공동소유설을 전제한 해석에 가깝고, 단체적 귀속설과 대법원 판례의 흐름을 충분히 반영하지 못한 것으로 평가될 수 있다.[26]

4. 과세요건과 면세규정의 관계, 그리고 petitio principii

조세법률주의는 헌법 제59조 및 제38조에 근거하여, 조세의 종목과 세율뿐 아니라 납세의무자, 과세물건, 과세표준, 납세기간 등 과세요건 전반과 조세의 부과·징수 절차를 법률로 규정할 것을 요구한다.[27] 이 원칙은 국민의 재산권을 침해하는

24) 비법인사단의 단체성은 민사소송법과 부동산등기법의 규율에서도 확인된다. 민사소송법 제52조는 "법인 아닌 사단 또는 재단도 대표자나 관리인을 통하여 당사자가 될 수 있다"고 규정하고, 부동산등기법 제26조는 비법인사단을 등기권리자·의무자로 인정하는 구조를 취한다. 이와 같은 소송법·등기법상의 규율과 총유에 관한 판례의 흐름을 종합하면, 비법인사단의 재산 귀속 구조를 "구성원 개인들의 공동소유"로 환원하기보다는 "단체 자체에 대한 단체적 귀속"으로 파악하는 것이 체계정합적이다.

25) 대법원 2005. 9. 15. 선고 2004다44971 전원합의체 판결: '비법인사단의 재산은 구성원 전체의 총유에 속하는 것으로서, 총유는 공유나 합유와 달리 각 구성원이 총유물에 대한 지분을 가지지 아니하고, 총유물의 관리 및 처분은 사원총회의 결의에 의하여야 한다.' 이 판결은 총유의 성질을 공유·합유와 구별하는 독자적 소유 형태로 명확히 하면서, 각 구성원의 지분 부재를 핵심 특징으로 제시하였다.

26) 이러한 논리는 독일 UmwG §202 Abs. 1 Nr. 1의 형태전환 동일성 원칙(Identitätsprinzip)과 유사한 발상을 공유한다. 독일 조직변경법상 동일성 원칙에 관하여는 이형규, "회사의 조직변경에 관한 입법론적 고찰", 법조 제66권 제1호, 법조협회, 2017, 277-311쪽.

27) 대한민국 헌법 제59조: '조세의 종목과 세율은 법률로 정한다.' 제38조: '모든 국민은 법률이 정하는 바에 의하여 납세의 의무를 진다.' 조세법률주의의 내용에 관하여는 이창희, 앞의 책, 47-52쪽; 임승순, 앞의 책, 119-122쪽; 허완중, 앞의 논문, 77-90쪽; 김영순, 앞의 논문, 545-558쪽.

공권력 행사에 법률의 수권을 필요로 한다는 법치주의의 논리적 귀결이면서, 동시에 국민이 자신의 조세 부담을 사전에 예측·계획할 수 있어야 한다는 권리 보호의 요청을 반영한다. 조세법률주의는 크게 과세요건법정주의와 과세요건명확주의, 그리고 소급과세금지원칙으로 구체화된다.[28]

헌법재판소 1992. 2. 25. 선고 90헌가69 결정은 조세법률주의가 과세요건법정주의와 과세요건명확주의를 그 핵심 내용으로 한다는 점을 확인하였다.[29] 과세요건법정주의는 납세의무의 성립과 내용을 형성하는 모든 요소가 법률에 명시되어야 한다는 것을 의미하며, 과세요건명확주의는 해당 법률 규정이 과세 여부를 예측 가능하게 하는 정도의 명확성을 갖추어야 함을 의미한다.[30] 이는 곧 해석을 통하여 새로운 과세요건을 창설하거나 기존 과세요건의 범위를 실질적으로 확장하는 것을 금지하는 기능을 수행하는 이상, 비전형적 사안에서 판례 일반론만을 근거로 과세를 정당화하기보다는, 문언과 체계에 비추어 해당 사안이 과세요건의 예정 범주에 속하는지 여부를 독자적으로 검토할 것을 요구한다. 요컨대 이 두 원칙의 결과로, 조세법규의 해석에 있어서 납세자에게 불리한 방향의 확장해석 또는 유추해석은 허용되지 않는다는 것이 대법원과 헌법재판소의 공통된 입장이다.[31]

한편 같은 단체라도 세목에 따라 취급이 달라지는바, 국세기본법 제13조 제2항은 법인 아닌 단체 중 수익을 구성원에게 분배하지 아니하는 것을 신청에 의하여 법인으로 보아 과세하고, 같은 조에 따라 법인으로 의제되는 단체는 법인세법상 납세의무를 진다. 반면 소득세법 제2조 제3항은 그 밖의 법인 아닌 단체에 대하여 구성원

28) 김성균, "과세요건 명확주의 관련 개별 법령에 대한 고찰", 공법학연구 제7권 제1호, 한국비교공법학회, 2006, 523-548쪽.

29) 헌법재판소 1992. 2. 25. 선고 90헌가69 결정(병합). 과세요건명확주의는 법률에 의하여 규정된 과세요건이 납세의무의 존부와 내용을 예측 가능하게 할 정도로 명확하여야 함을 의미한다. 한편 소급과세금지원칙을 조세법률주의의 내용으로 포함하는 취지에 관하여는 헌법재판소 2012. 5. 31. 선고 2009헌바123 결정 등 참조.

30) 법학방법론에서 제기된 '법문언의 가능한 의미'와 법형성 논쟁은 조세법 해석에서도 유의미한 시사점을 제공한다. 조세법률주의 및 과세요건명확주의는 세법 해석에서도 허용되는 해석과 금지되는 유추의 경계를 분명히 할 것을 요구하며, 차용개념에 대한 해석 역시 그 문언과 법체계, 헌법상 권리보호 기능에 비추어 이러한 경계를 넘지 않는 범위에서만 이루어져야 한다.

31) 헌법재판소 2012. 5. 31. 선고 2009헌바123 결정은 전부개정으로 실효된 조세감면규제법 부칙 조항을 계속 과세요건으로 해석한 대법원 판례를 조세법률주의 및 권력분립 원칙 위반으로 보아 한정위헌을 선언하였다. 이 결정은 규정의 부재를 이유로 과세요건의 존재를 추론하는 것은 사법부가 입법부의 입법 형성 영역을 침범하는 것에 해당한다고 보았다. 대법원 2004. 5. 28. 선고 2003두7392 판결; 대법원 1999. 1. 15. 선고 97누20304 판결; 대법원 2001. 12. 14. 선고 2000두8622 판결 등 다수.

간 이익의 분배비율이 정하여져 있는지 등에 따라 이를 1거주자로 보거나 각 구성원별로 과세하도록 한다. 요컨대 법인세법과 소득세법은 법인 아닌 단체의 과세 취급을, 그 명의나 등기의 형식이 아니라 이익의 분배 여부와 단체로서의 실체라는 실질을 기준으로 결정한다.[32]

Ⅳ. 대상 판결의 논증 구조와 비판

이하에서는 Ⅲ장에서 정립한 법리적 틀을 바탕으로, ① 부산고등법원 2023. 11. 24. 선고 2023누22276 판결의 논증 구조를 비판적으로 분석하고, ② 서울행정법원 2005. 2. 15. 선고 2004구합17839 판결의 시사점과 보완 방향을 평가하며, ③ 두 판결이 조세법 해석방법론의 스펙트럼에서 차지하는 위치를 종합적으로 고찰하고자 한다.[33]

1. 부산고등법원 2023. 11. 24. 선고 2023누22276 판결 논리의 구조와 한계

Ⅱ.3.에서 정리한 바와 같이, 이 판결의 논증 구조는 ① 취득세 유통세론의 전제 설정, ② 총유에서 법인 단독소유로의 전환을 권리주체 변경으로 등치, ③ 감면규정 부재에 따른 과세 필요성 확인이라는 세 단계로 구성된다. 이 구조는 형식상 전제→포섭→결론의 연역적 삼단논법을 따르나, 각 단계의 논증 내용을 면밀히 분석하면

32) 이러한 다른 세목의 태도는 본고의 논지와 두 가지 점에서 맞닿는다. 첫째, 단체의 동일성과 실질을 과세의 기준으로 삼는 것은 이미 세법 체계 전반에 내재한 원리이므로, 취득세에서 단체의 실질적 동일성을 기준으로 삼는 해석은 세법 체계 전체의 정합성에 부합한다. 둘째, 비법인사단이 사단법인으로 전환하면 그 단체는 더 이상 이익의 분배 여부에 따라 과세 단위가 좌우되는 지위가 아니라 법인세법상 법인으로서 일원적으로 과세되는 지위로 옮겨 간다. 이러한 과세지위의 전환이야말로 법인격 취득에 따르는 실질적 효과이며, 대상판결이 법인전환에 새로운 '취득'의 외형을 부여하려 한 배경에도 이와 같은 지위 변동을 '담세력 있는 변화'로 본 시각이 자리할 수 있다. 그러나 과세지위의 전환은 단체의 소득과 분배 국면에서 평가되어야 할 사정일 뿐, 단체가 보유한 개별 부동산에 관하여 새로운 권리이전이 있었다고 의제할 근거가 되지는 못한다. 세목별 과세 단위의 차이를 취득세 과세요건의 충족으로 직접 치환하는 것은, 앞서 본 과세요건 엄격해석의 요청과 조화되기 어렵다. 이하 서울고등법원 2020. 5. 13. 선고 2019누53725 판결.

33) 부산고등법원 2023누22276 판결의 논증 구조에 관한 분석은 전술 Ⅱ.3. 참조

방법론적 문제가 드러난다. 이하에서는 각 단계별로 이를 순차적으로 검토한다.

(1) 취득세 유통세론 전제의 설정과 그 한계

이 판결의 첫 번째 단계는 대법원의 확립된 판례 법리인 취득세 유통세론을 원용하는 것이다. 판결은 '취득세는 부동산의 취득이라는 사실 자체를 포착하여 담세력을 인정하는 유통세의 일종'이라는 대법원 판시를 인용하고, 이로부터 등기원인과 무관하게 소유권이전의 형식이 갖추어진 경우에는 취득세 과세요건이 충족된다는 일반 명제를 도출하였다.

대법원의 유통세 판시는 전형적인 매매·증여와 같이 서로 독립된 권리주체 사이에서 대가의 지급 또는 증여의 의사표시에 따라 소유권이 이전되는 사안을 중심으로 형성된 것이다. 특히 유통세설이 취득세의 법적 성격을 설명하는 이유는, 재화의 이전이라는 외관을 통하여 새로운 담세력의 발생을 포착하려는 데 있다. 전형적인 매매·증여·교환에서는 소유권이전등기라는 형식적 사건이 곧 새로운 경제적 지배권의 취득과 결부되어, 재산권의 주체가 실질적으로 교체되고 그에 상응하는 세부담능력이 발생한다. 그러나 비법인사단의 법인전환과 같이 전환 전후에 동일한 단체가 부동산을 계속 지배·사용하고, 구성원·목적 사업·자산·부채 구조에 본질적인 변화가 없는 사안에서는, 명의 변경만으로 새로운 담세력이 발생한다고 보기는 어렵다. 이와 같은 경우 소유권이전등기는 실질적 권리귀속 관계의 변동이 아니라 기존 관계의 법적 외형 정비에 불과하며, 담세력 포착이라는 유통세설의 기능도 작동하지 않는다. 그럼에도 대상판결은 유통세 일반론을 전제로 소유권이전등기가 있다는 사실만으로 과세요건으로서의 '취득'을 곧바로 긍정함으로써, 유통세설이 전제하는 경제적 실질과 담세력 구조를 충분히 검토하지 않은 채 결론을 선취하고 있다.[34]

나아가 조세법률주의는 각 사안에서 과세요건 충족 여부를 독립적으로 검토할 것을 요구한다. 이는 선례 법리의 적용 가능성 자체를 해당 사안의 특성에 비추어 먼저 검증하여야 함을 의미한다.[35] 유통세론의 일반 명제를 조직 변경 사안에 적용하

34) 유통세론이 전형적 매매·증여 사안을 전제로 형성된 것이므로 비전형적 사안에 무비판적으로 적용하는 것의 위험성에 관하여는 최원, 앞의 논문, 196-205쪽. 부산고등법원 2023누22276 판결 이유 제3항은 '취득세는 부동산 소유권의 취득이라는 사실 자체를 포착하는 유통세'라는 표현으로 이 전제를 명시하였다.

기 위해서는, '취득세 과세의 근거가 되는 재화의 이전 또는 담세력의 발생이 이 사안에서도 존재하는가'라는 실질적 물음에 먼저 답하여야 한다. 실제로 대법원은 일부 판결에서 형식적 명의변동만으로는 취득세 과세요건이 충족되지 않을 수 있음을 시사한 바 있어, 유통세론이 실질 검토를 전적으로 배제하지 않음을 보여주기도 한다.[36]

판결이 유통세론을 전제로 삼아 실질 동일성 주장을 배척하는 논리 구조는, 해석의 출발점이 특정 방향으로 고정된 채 해당 사안의 구체적 특성에 대한 독립적 검토가 생략된 사례로 평가될 수 있다. 조세법률주의의 요청에 부합하는 해석을 위해서는 유통세론의 전제를 이 사안에 적용하는 타당성에 관한 독자적 검토가 논증의 출발점이 되어야 하였다.

(2) 총유에서 법인 단독소유로의 전환을 권리주체 변경으로 등치하는 논리의 문제

판결의 두 번째 단계는 비법인사단의 재산 귀속 형태인 총유와 사단법인의 법인 단독소유 사이의 차이를 '권리주체의 변경'으로 직접 연결하는 것이다. 판결은 총유에서는 구성원 전체가 권리 귀속 주체이고, 법인 단독소유에서는 법인 자체가 권리 귀속 주체이므로, 총유에서 법인 단독소유로의 전환은 권리주체의 교체를 의미한다는 논리를 취하였다.[37]

그러나 이 논리는 총유의 법적 성질에 관한 학설 대립—공동소유설과 단체적 귀속설의 대립—을 충분히 고려하지 않은 채 공동소유설의 입장을 당연한 전제로 취하는 것이다. 단체적 귀속설에 의하면 총유의 실질적 권리 귀속 주체는 구성원 개인들이 아니라 단체 자체이므로, 법인전환 이후에도 동일한 단체가 권리 귀속 주체라는 점에서 권리주체의 변경은 발생하지 않는다고 보게 된다.[38] 더욱이 대법원 2004다

35) 조세법률주의가 과세요건 충족 여부를 사안별로 독립적으로 검토할 것을 요구한다는 점에 관하여는 이창희, 앞의 책, 61-62쪽; 헌법재판소 2012. 5. 31. 선고 2009헌바123 결정 이유 III.3.나. 부분 참조. 이창희, 앞의 책, 884쪽: '취득세의 유통세적 성격은 과세의 목적과 근거에 관한 설명으로서의 의미를 가지나, 이로부터 형식적 이전만으로 언제나 취득세 과세요건이 충족된다는 결론이 자동적으로 도출되는 것은 아니다.'

36) 대법원 2018. 3. 22. 선고 2014두43110 전원합의체 판결(전술 Ⅲ.1. 각주 참조). 임승순, 앞의 책, 702-703쪽.

37) 부산고등법원 2023누22276 판결 이유 제4항. 판결은 '비법인사단의 재산은 구성원 전원의 총유에 속하나, 사단법인의 재산은 법인 단독소유에 속하므로 권리의 귀속 주체가 달라진다'는 취지로 판시하였다. 총유의 법적 성질 및 공동소유설·단체적 귀속설의 대립에 관하여는 전술 Ⅲ.3. 참조.

44971 전원합의체 판결의 취지가 총유의 실질 귀속 주체를 구성원 개인으로 확정하는 것이 아니라, 총유의 소유 구조적 독자성을 강조하는 것에 있다는 해석도 충분히 가능하다.[39]

나아가 판결은 이 사건 A단체가 사단법인으로 전환하는 과정에서 사단성 요건(대법원 1999. 4. 23. 선고 99다4504 판결 등이 제시하는 단체의 조직, 다수결원칙, 구성원 변경에도 불구한 단체 존속, 대표 방법 등)이 전환 전후에 걸쳐 실질적으로 동일하게 유지되었는지에 관한 검토를 생략하였다.[40] 취득세 과세요건으로서의 '취득'이 민사법상의 소유권 변동과 반드시 일치하는 것은 아니므로, 민법상 소유형태의 차이를 조세법적 취득의 요건으로 직접 원용하는 논리에는 세법의 차용개념론 검토가 추가적으로 요구된다. 그러나 판결은 이 연결의 타당성을 지지하는 독자적 논증 없이 민사법상의 귀속 형태 차이를 곧바로 과세요건 충족의 근거로 삼았다는 점에서 논증의 완결성이 미흡하다.[41]

(3) 감면규정 부재·입법공백의 원용과 선결문제 요구의 오류

판결의 세 번째 단계는 지방세법에 비법인사단의 법인전환에 따른 부동산 이전을

38) 단체적 귀속설의 논거와 대법원 2005. 9. 15. 선고 2004다44971 전원합의체 판결의 해석에 관하여는 전술 Ⅲ.3. 참조. 학설 대립이 해결되지 않은 상황에서 일방 학설을 전제로 과세 결론을 도출하는 것은 납세자에게 불리한 방향으로 모호성을 해소하는 것으로서 '의심스러울 때는 납세자에게 유리하게(in dubio pro tributario)'원칙과 긴장을 형성할 수 있다.

39) 비법인사단은 민사소송법 제52조와 부동산등기법 제26조에 따라 독자적인 소송당사자 및 등기권리자의 지위를 인정받고 있고, 대법원 역시 비법인사단 명의의 등기·소송을 꾸준히 허용해 왔다. 이는 비법인사단이 단순히 구성원들의 집합이 아니라, 법질서 내에서 일정한 권리·의무의 주체로 기능하고 있음을 의미한다.

40) 대법원 1999. 4. 23. 선고 99다4504 판결 참조. 비법인사단이 주무관청의 인가를 받아 사단법인으로 전환될 때에는 이미 그 설립인가 과정에서 단체의 목적·조직·재산 등이 심사된다는 점에서(민법 제32조), 전환 전후 사단성 요건의 실질적 동일성을 추정할 수 있는 논거가 성립할 수 있다. 임승순, 앞의 책, 120-124쪽.

41) 나아가 조합원이 조합에 부동산을 현물출자하는 경우에는 그 재산이 조합원의 합유로 되어 '양도'에 해당한다고 보아 양도소득세 과세대상으로 본 사례가 있다(대법원 1985. 4. 23. 선고 84누680 판결). 그러나 이는 합유로의 권리 귀속 변동이 인정되는 경우로서, 총유에 속하던 비법인사단의 재산이 동일한 단체의 법인격 취득에 따라 그대로 승계되는 본 사안과 그 구조를 달리한다. 한편 조세심판원 2010. 3. 31. 조심2009서4094 결정은 개인 간 공동사업에 토지를 제공한 것이 양도소득세 과세대상인 현물출자에 해당하는지를 공동사업의 성격과 제공자의 의사를 감안하여 판단하여야 한다고 보아, 형식만으로 현물출자(양도)를 단정하지 않았다. 이러한 태도는 형식적 외관보다 거래의 실질을 중시하여야 한다는 본고의 논지와 궤를 같이한다. 이하 대법원 1985. 4. 23. 선고 84누680 판결 및 조세심판원 2010. 3. 31. 조심2009서4094 결정; 윤병철. "현물출자와 세법상 논점", 조세법연구 제11집 제2호, 한국세법학회, 2005, 15-17쪽.

취득세 과세대상에서 제외하거나 감면하는 규정이 존재하지 않는다는 점을 과세 긍정의 보완 근거로 삼는 것이다.[42] 그러나 이 논거는 논리적으로 선결문제 요구의 오류(petitio principii)에 해당하는 것으로 보인다. 감면규정은 납세의무의 성립을 전제로 그 의무의 일부 또는 전부를 해제하는 규정이므로, 납세의무의 성립—즉 과세요건의 충족—이 먼저 확립되어야 비로소 감면규정의 유무가 의미를 가질 수 있다. 결론적으로 감면규정 부재의 원용은 과세요건이 성립한다는 결론을 전제로 한 후행 논증일 뿐, 과세요건 성립을 위한 선행 논거가 될 수 없다.[43]

판결이 원용한 지방세법 제15조의 합병 특례 규정은, 합병에 따른 취득이 원칙적으로 취득세 과세요건을 충족함을 전제로 세율 특례를 부여하는 구조이다. 이와 대비하여 비법인사단 법인전환에 관한 별도 규정이 없다는 것은 두 가지 서로 다른 의미로 해석될 수 있으며, 이 두 가능성 사이의 모호성을 납세자에게 불리한 방향으로 해소하는 것은 헌법재판소 2009헌바123 결정이 확인한 원칙에 배치될 수 있다.[44] 나아가, 법률에 명시적 규정이 없는 거래 유형에 대하여 유사 규정이 있는 합병 특례를 반대 해석의 논거로 활용하는 것은 과세요건의 창출을 의미할 수 있어, 세법상 유추해석금지 원칙과도 긴장을 형성한다.[45]

---

42) 부산고등법원 2023누22276 판결 이유 제5항. 판결은 '지방세법 제15조 등에서 합병 등 일부 형식적 취득에 관하여 특례를 두고 있으나, 비법인사단의 법인전환에 따른 부동산 이전을 과세대상에서 제외하거나 감면하는 규정이 존재하지 않는다'는 취지로 판시하였다. 조세법에서 감면규정은 이미 납세의무가 성립한 것을 전제로 그 의무의 일부 또는 전부를 해제하는 규정으로서, 과세요건의 성립 여부와는 논리적으로 단계를 달리한다.

43) 이러한 논증 방식은 헌법재판소 2009헌바123 결정의 취지와도 충돌할 위험이 있다. 감면규정의 부재를 근거로 과세요건의 성립을 긍정하는 것은, 입법자가 명문으로 규정하지 않은 과세요건을 법원이 해석을 통하여 사실상 창설하는 결과를 초래할 수 있기 때문이다. 규범의 공백 또는 해석상 모호성이 존재하는 경우, 그 불확실성을 납세자에게 불리한 방향으로 해소하여 과세요건의 존재를 인정하는 것은 '의심스러울 때는 납세자에게 유리하게(in dubio pro tributario)' 원칙이 요청하는 해석 태도와도 정면으로 배치된다.

44) 비법인사단의 법인전환에 관한 지방세법상 특례 규정의 부재는 두 가지 다른 의미로 해석될 수 있다. 하나는 입법자가 해당 이전을 과세대상으로 의도하였으나 감면규정을 두지 않은 경우이고, 다른 하나는 입법자가 해당 이전을 처음부터 취득세 과세요건 미충족으로 파악하여 별도 규정이 불필요하다고 본 경우이다. 헌법재판소 2012. 5. 31. 선고 2009헌바123 결정은 '과세요건의 존재 여부는 입법의 문제이지, 규정의 부재를 이유로 과세요건이 존재한다고 추론할 수 없다'는 취지를 명확히 하였다. 이하 이재호, 앞의 논문, 161-165쪽.

45) 이창희, 앞의 책, 62-63쪽; 최성근, "실질과세원칙에 관한 법리와 규정에 대한 분석 및 평가", 조세법연구 제19집 제2호, 한국세법학회, 2013, 119-152쪽.

2. 서울행정법원 2005. 2. 15. 선고 2004구합17839 판결의 시사점과 보완 과제

(1) 시사점

서울행정법원 2004구합17839 판결은, 비법인단체에서 재단법인으로의 전환 과정에서 이루어진 부동산 이전등기를 취득세 과세대상으로 볼 수 없다고 판단하였다. 이 판결의 방법론적 의의는 등기원인에 기재된 '증여'라는 형식을 과세요건 충족의 자동적 근거로 보지 않고, 거래의 실질을 독자적으로 탐구하였다는 점에 있다.[46] 이는 지방세법 제7조 제2항의 '사실상 취득' 개념과도 연결되는 논리로서, 형식과 실질의 구별을 조세법률주의의 요청으로 이해한 것으로 평가된다. 한편 전환 전후 단체의 실질적 동일성이 유지되어 새로운 취득이 부정되는 경우에도, 사단법인 명의로의 소유권이전등기 자체는 필요하다. 이때의 등기는 별개의 권리주체 사이의 권리이전이 아니라, 동일한 단체가 법인격을 취득하면서 종전의 총유 명의를 법인 단독명의로 정리·승계하는 절차에 해당한다. 그러므로 그 등기원인은 '증여'가 아니라 법인전환에 따른 권리승계로 보는 것이 거래의 실질에 부합할 것이다.

이 판결은 대법원이 2012년 전원합의체 판결에서 확인한 실질과세 원칙—납세의무의 귀속과 내용은 그 경제적 실질에 따라 결정된다는 원칙—과도 방향을 같이한다.[47] 조직법적 변경에 수반된 명의 이전이 실질적 권리변동을 내포하는지 여부를 형식이 아닌 실질을 중심으로 탐구한 것은, 과세요건의 엄격 해석과 실질 기반 판단이라는 이중의 요청을 동시에 충족하는 방향성을 보여 준다.

그러나 이 판결이 실질 판단의 기준으로 제시한 '전환 전후 단체의 실질적 동일성'은, 그 법률적 근거와 구체적 판단 기준이 명시되지 않은 채 사실 인정의 수준에서 처리되었다는 한계를 갖는다. 이는 이후 반대 결론의 판결—부산고등법원 2023누22276—이 실질 동일성론을 '법률에 명문 근거가 없는 임의적 기준'으로 배척할 수 있는 논증 공간을 허용하였다.

---

46) 서울행정법원 2005. 2. 15. 선고 2004구합17839 판결의 사안과 논거에 관하여는 전술 Ⅲ.1. 참조. 이 판결의 이론적 기여는 세법상 '취득'의 존부를 등기원인의 기재 형식이 아닌 거래 실질을 기준으로 판단하여야 한다는 원칙을 선언하였다는 점에 있다.

47) 대법원 2012. 1. 19. 선고 2008두8499 전원합의체 판결: '세법의 해석과 적용에 있어서는 과세요건 법정주의 및 과세요건 명확주의를 기본원칙으로 하면서도, 그 경제적 실질에 따라 납세의무의 귀속과 내용을 정함으로써 조세부담의 공평을 기하여야 한다.' 이창희, 앞의 책, 68-73쪽.

(2) 보완과제

이 판결이 보완되어야 할 논증의 방향은 세 가지로 정리된다. 첫째, 지방세법 제6조 제1호가 취득의 원인으로 열거하는 매매·증여·상속 등은 모두 별개의 권리주체 사이에서 권리가 이전되는 경우를 전형으로 삼는다는 점에서, 동일한 실질적 권리귀속 주체가 유지되는 조직 변경은 이 열거의 예정 범주 밖에 있다는 체계적 해석론이 제시되어야 하였다. 둘째, 지방세법 제7조 제2항의 '사실상 취득' 개념도 별개 주체 사이의 실질적 지배권 이전을 요건으로 하는 것임을 논증함으로써, 형식적 등기뿐 아니라 실질적 취득도 부재함을 보여 주어야 하였다. 셋째, 사단성 요건의 전환 전후 동일성을 '실질적 동일성'의 법적 기준으로 명시함으로써, 조직 변경 과세 면제의 요건을 구체화하였어야 하였다.

이러한 보완 방향은 현행 지방세법의 문언과 체계 안에서 도출 가능한 것으로서, 법관의 해석이 입법의 영역을 침범하지 않는 범위 내의 법해석론에 해당한다. 이와 같은 논증 체계가 갖추어진다면, 서울행정법원 판결이 지향한 결론은 조세법률주의와 체계 정합적인 법해석의 산물로서 보다 강력한 설득력을 확보할 수 있었을 것이다.

(3) 보론: 실질적 동일성 판단의 객관화를 위한 제언

실질적 동일성 판단을 보다 객관화하기 위해서는, 몇 가지 지표를 기준으로 삼을 수 있다. 첫째, 구성원의 승계율이다. 이는 전환 전 비법인사단의 구성원 중 일정 비율 이상이 전환 후 사단법인의 회원으로 승계되는지 여부이다. 둘째, 단체의 목적과 주요 사업 내용의 연속성으로서, 정관상 목적·사업 항목이 전환 전후에 걸쳐 본질적으로 동일하게 유지되는지 여부이다. 셋째, 재산 승계 방식으로서, 비법인사단의 기본재산이 전부 또는 대부분 사단법인에 무상으로 승계되는지, 또는 전환 과정에서 제3자에게 유상 양도가 병행되는지 여부이다. 넷째, 의사결정 구조의 동일성으로서, 전환 전후에 총회·이사회 등 핵심 기관의 구성·권한과 의사결정 절차가 실질적으로 유지되는지 여부이다.

이러한 지표는 임의로 설정한 것이 아니라 현행법의 문언과 요건에서 도출된다. 구성원의 승계와 의사결정 구조의 동일성은 단체의 조직, 다수결의 원칙, 구성원의 변경에도 불구한 단체의 존속, 대표의 방법 등 사단성 요건에 관한 대법원 1999.

4. 23. 선고 99다4504 판결의 기준에 대응한다. 목적·사업의 연속성과 기본재산의 무상 승계 여부는 민법 제275조·제276조가 정한 총유의 구조[48] 및 지방세법 제6조 제1호·제7조 제2항의 '사실상 취득' 문언과 연결된다. 나아가 이러한 실질을 기준으로 과세 여부를 판단하는 것은 대법원 2012. 1. 19. 선고 2008두8499 전원합의체 판결이 확인한 실질과세의 원칙에도 부합한다.

이러한 요소들을 종합적으로 검토하여 단체의 인적·목적·조직·재정 구조가 연속성을 유지하는 경우에는 조직법상 동일성이 인정된다고 보아 취득세 과세요건으로서의 '취득'을 부정하고, 반대로 이러한 요소들이 중대하게 변경된 경우에는 실질적 권리주체 변경이 인정될 여지가 있다는 기준을 제시할 수 있을 것이다.

3. 조세법 해석방법론의 관점에서 본 두 판결의 위치

두 판결의 법리적 위치를 조세법 해석방법론의 세 원칙—조세법률주의, 실질과세, in dubio pro tributario—에 비추어 종합적으로 평가하면 다음 〈표 1〉과 같다.

〈표 1〉 두 판결의 조세법 해석방법론 비교

해석 원칙	부산고등법원 2023. 11. 24. 선고 2023누22276	서울행정법원 2005. 2. 15. 선고 2004구합17839
조세법률주의 -과세요건 엄격 해석	유통세론 전제를 자명하게 원용하여 과세요건의 독립적 성립 여부를 검토하지 않음 → 납세자 불리 확장해석 가능성	형식적 등기원인을 넘어 실질을 중심으로 취득 여부를 판단 → 엄격 해석 원칙에 부합
실질과세 원칙 -대법원 2008두8499 전원합의체	등기원인 '증여'라는 형식을 우선하여 실질(단체 동일성)을 고려하지 않음 → 실질과세 원칙과 긴장	단체의 인적·물적 동일성이라는 실질을 과세요건 판단의 기준으로 삼음 → 실질과세 방향에 부합
In dubio pro tributario 납세자 유리 해석	학설·법리상 모호성이 존재함에도 납세자 불리 방향으로 해소 → 원칙에 배치될 소지	모호성 상황에서 비과세 방향으로 해소 → 원칙에 부합

48) 김민주. "비법인사단 관련 규정에 대한 소고-민법 제32조 허가주의와 제275조 이하 총유규정을 중심으로-". 원광법학 제30권 제3호, 원광대학교 법학연구소, 2014, 377-381쪽.

첫째, 조세법률주의와의 관계에서 볼 때, 부산고등법원 판결은 대법원 판례의 문언을 형식적으로 준수하면서도 그 판례가 전제하는 전형적 사안과 이 사건 사안의 구조적 차이를 검토하지 않은 채 선례를 기계적으로 적용하였다는 점에서 조세법률주의의 요청과 긴장을 형성한다고 볼 여지가 있다.[49]

둘째, 실질과세 원칙과의 관계에서, 부산고등법원 판결은 등기원인 '증여'라는 형식을 실질에 앞세움으로써 실질과세 원칙의 방향과 배치되는 결론에 이를 가능성이 있다. 이 점과 관련하여, 실질과세 원칙이 납세자에게 불리한 방향으로도 작동할 수 있다는 반론이 있을 수 있으나, 이 사건에서 실질은 권리변동의 부재, 즉 취득의 불성립을 가리키므로 실질과세 원칙의 적용이 납세자에게 유리한 방향으로 작동한다는 점을 주목할 필요가 있다.

셋째, in dubio pro tributario 원칙과의 관계에서 볼 때, 이 사건에서 과세요건 충족 여부에 관한 학설상 논란과 법리상 모호성이 존재하는 이상, 이 모호성은 납세자에게 유리한 방향으로 해소되어야 한다는 것이 이 원칙의 요청이다.[50]

Ⅴ. 결론

1. 요약

본고는 비법인사단이 사단법인으로 전환하는 과정에서 이루어지는 부동산 이전등기가 지방세법상 취득세 과세요건으로서의 '취득'에 해당하는지 여부를 둘러싸고, 부산고등법원 2023. 11. 24. 선고 2023누22276 판결과 서울행정법원 2005. 2.

49) 조세법률주의 원칙과 관련하여 부산고등법원 2023누22276 판결을 평가하면, 동 판결은 형식적으로 대법원 판례의 법리를 인용하였으나, 과세요건의 독립적 성립 여부를 검토하지 않고 유통세론을 과세요건 존재의 전제로 활용하는 구조를 취하였다는 점에서 조세법률주의의 요청을 완전히 충족한다고 보기 어렵다. 이재호, 앞의 논문, 141-148쪽. 반면 서울행정법원 판결은 과세요건의 충족 여부를 독립적으로 탐구함으로써 조세법률주의의 정신에 보다 가까운 접근을 취하였으나, 법률적 근거 제시의 미흡으로 방법론적 완결성이 충분히 확보되지는 못하였다.

50) 실질과세 원칙(대법원 2008두8499 전원합의체 판결)과의 관계에서 볼 때, 부산고등법원 판결은 등기원인 '증여'라는 형식을 실질보다 우선시하였는데, 이 사건에서 실질은 권리변동의 부재를 가리키므로 실질과세 원칙의 적용이 납세자에게 유리한 방향으로 작동함에도 이를 고려하지 않은 측면이 있다. in dubio pro tributario 원칙에 관하여는 전술 Ⅲ.2. 및 이재호, 앞의 논문, 161-165쪽.

15. 선고 2004구합17839 판결이 상반된 결론에 이른 이유를 조세법률주의의 관점에서 분석하였다. 이를 위하여 먼저 취득세의 법적 성격(유통세설·권리변동세설), 세법의 차용개념론, 비법인사단 재산의 총유 구조와 단체 동일성, 조세법률주의 및 유추해석금지·in dubio pro tributario 원칙을 검토하고, 이러한 법리적 틀 속에서 두 판결의 논증 구조와 해석방법론적 성격을 비교하였다. 그 결과, 대상판결은 유통세 일반론의 비판적 검토 없는 전제 설정, 총유와 법인 단독소유의 형식적 차이를 권리주체 변경으로 곧바로 등치하는 포섭, 감면규정 부재를 과세요건 성립의 논거로 원용하는 petitio principii 구조를 통해 조세법률주의와 실질과세, in dubio pro tributario 원칙과 긴장을 형성하는 반면, 서울행정법원 판결은 형식보다 실질을 중시하는 방향성과 차용개념론적 문제의식에서 일정한 타당성을 보이되, 논증 체계의 명시성에서 한계를 드러내는 것으로 평가되었다.

본고가 제시한 해석론은 다음과 같이 요약될 수 있다. 첫째, 취득세의 유통세적 성격을 인정하면서도, 비법인사단의 법인전환과 같이 권리주체 동일성이 문제되는 사안에서는 유통세 일반론만으로 과세요건 충족 여부를 자동적으로 결정할 수 없고, 전환 전후 단체의 실질적 동일성과 재산의 실질적 귀속 구조에 대한 추가적인 검토가 요구된다.

둘째, 비법인사단 재산의 총유에 관하여 단체적 귀속설과 친화적인 대법원 판례의 흐름과 사단성 요건을 고려할 때, 전환 전후 단체의 목적·구성원·의사결정 구조·재정 운용 등 핵심 요소가 유지되는 경우에는 실질적 권리귀속 주체가 동일한 단체로 남아 있다고 보아야 하며, 이러한 경우 비법인사단에서 사단법인으로의 전환에 수반된 부동산 이전을 지방세법상 '취득'으로 볼 수 없다. 최근 대법원도 실질적 소유권 변동이 없는 경우 취득을 부정하는 경향을 보인다.[51]

셋째, 과세요건과 면세·감면규정은 그 기능이 엄격히 구별되므로, 비법인사단의 법인전환에 관한 명시적 비과세·감면규정의 부재는 그 자체로 과세요건 성립의 근거가 될 수 없고, 오히려 과세요건 해석의 불명확성과 해석론만으로는 해소되기 어

51) 대법원 2026. 4. 16. 선고 2025두35956 판결은 수탁자에게 실질적 관리·처분 권한이 없는 신탁에 기한 위탁자 지위 이전을 취득으로 보기 어렵다고 보아 원심을 파기환송하였다. 다만 이는 신탁 사안으로서 본 사안과 사실관계를 달리하므로, 실질적 소유권 변동이 없는 경우 취득을 부정한다는 일반적 경향을 보여주는 한도에서 인용한다.

려운 실무상의 혼란을 드러내는 지표로 이해되어야 한다.

2. 입법론으로의 지향

그러나 이러한 해석론만으로는 동일 유형 사안에 대한 하급심 판결의 불일치와 납세자의 예측가능성 부족 문제를 근본적으로 해결하기 어렵다. 이는 취득세 유통세론과 권리변동세설, 차용개념론, 총유의 법적 성질, 조세법률주의 및 실질과세 원칙과 같이 복수의 법리 축이 교차하는 영역에서, 해석자가 어느 축을 얼마나 중시하는지에 따라 결론이 달라질 수 있기 때문이다. 특히 비법인사단의 법인전환에 수반된 부동산 이전에는 실무적으로 상당한 규모의 취득세 부담이 수반될 수 있고, 헌법 제23조가 보장하는 재산권과 직접적으로 연결되는 점을 감안하면, 과세요건 해석을 해석자의 재량에 맡겨 두는 현재의 상태는 바람직하지 않다. 조세법률주의 및 과세요건명확주의의 관점에서 보면, 이 사안은 입법자가 '취득' 개념의 적용 범위를 보다 명확하게 정립함으로써 해석상의 불확실성과 과잉과세 위험을 줄여야 할 영역으로 보아야 한다.

이에 따라 본고는 비법인사단이 실질적 동일성을 유지한 채 사단법인으로 전환하는 과정에서 이루어지는 부동산 이전에 대하여, 해석론과 병행하여 다음과 같은 입법적 정비 방향을 제안하였다. 첫째, 지방세법 제6조 제1호의 '취득' 정의 규정 또는 제7조의 납세의무 규정에 "조직법상 동일성이 유지되는 비법인사단의 사단법인 전환에 수반된 재산 이전은 취득에 해당하지 아니한다"는 취지의 예외 규정을 명시함으로써, 실질적 동일성 유지 시 비과세 원칙을 선언하는 방안이 있다.

둘째, 보다 신중한 접근으로서, 지방세법에 별도의 비과세·감면 규정을 신설하여, 일정한 요건(예컨대 사단성 요건의 연속성, 재산의 동일 목적 사용, 구성원 구조의 실질적 유지 등)을 충족하는 비법인사단의 법인전환 사안에 대하여 취득세를 비과세하거나 감면하는 방안도 고려할 수 있다. 한 가지 입법적 정비 방안으로는 지방세법 제6조 제1호의 '취득' 정의 규정에 다음 〈표 2〉와 같은 단서 규정을 추가하는 방안을 생각해 볼 수 있다.

〈표 2〉 지방세법 제6조 제1호 개정안

현행	개정안
제6조(정의) 취득세에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다. 1. “취득”이란 매매, 교환, 상속, 증여, 기부, 법인에 대한 현물출자, 건축, 개수(改修), 공유수면의 매립, 간척에 의한 토지의 조성 등과 그 밖에 이와 유사한 취득으로서 원시취득(수용재결로 취득한 경우 등 과세대상이 이미 존재하는 상태에서 취득하는 경우는 제외한다), 승계취득 또는 유상 · 무상의 모든 취득을 말한다. 〈신설〉	제6조(정의) 현행과 같음 1. (생략). 다만 법인 아닌 사단이 「민법」제32조에 따른 인가를 받아 사단법인으로 전환하는 경우로서, 전환 전후의 단체가 그 목적·구성원·조직 및 재산을 실질적으로 동일하게 유지하면서 종전 재산을 승계하는 때에는 그 명의 변경을 취득으로 보지 아니한다.

이와 같은 단서 규정은 비법인사단에서 사단법인으로의 전환 과정에서 조직법상 동일성이 유지되는 사안에 대하여, 지방세법상 ‘취득’ 개념의 적용 범위를 명시적으로 한정함으로써, 이 글에서 제시한 “실질적 동일성 유지 시 취득 부정”이라는 해석론을 입법 수준에서 확인해 주는 기능을 수행할 수 있다.

다른 방안으로는 지방세법 제15조(세율의 특례)에 다음과 같은 비과세 특례 규정을 신설하는 것도 가능하다.

〈표 3〉 지방세법 제15조 개정안

현행	개정안
제15조(세율의 특례) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 취득에 대한 취득세는 제11조 및 제12조에 따른 세율에서 중과기준세율을 뺀 세율로 산출한 금액을 그 세액으로 하되, 제11조제1항제8호에 따른 주택의 취득에 대한 취득세는 해당 세율에 100분의 50을 곱한 세율을 적용하여 산출한 금액을 그 세액으로 한다. 다만, 취득물건이 제13조제2항에 해당하는 경우에는	제15조(세율의 특례) (생략) 8. 법인 아닌 사단이 「민법」 제32조에 따른 인가를 받아 사단법인으로 전환하면서 종전 재산을 승계하는 경우로서, 전환 전후 단체의 목적·구성원·조직 및 재산이 대통령령으로 정하는 기준에 따라 실질적으로 동일하다고 인정되는 때에는 그 전환에 수반된 부동산 등의 취득에 대하여는 취득세를 부과하지 아니한다.

현행	개정안
이 항 각 호 외의 부분 본문의 계산방법으로 산출한 세율의 100분의 300을 적용한다. 1.~7. (생략) 〈신설〉	

이와 같은 규정은 조직변경 사안에서 취득세를 전면적으로 배제하는 대신, 실질적 동일성 요건을 충족하는 범위 내에서만 비과세를 인정함으로써, 조세 중립성과 과세 형평 사이의 조화를 도모하는 입법 모델이 될 수 있다. 여기서 '대통령령으로 정하는 기준에 따라 실질적으로 동일하다고 인정되는 때'란, 앞서 제시한 네 가지 지표—구성원의 승계, 목적·사업의 연속성, 기본재산의 무상 승계, 의사결정 구조의 유지—를 시행령에 구체적 요건으로 규정함으로써 정해질 수 있다. 이 정도로 요건을 구체화한다면 과세 여부의 예측이 가능하므로, 헌법재판소 1992. 2. 25. 선고 90헌가69 결정이 요구하는 과세요건명확주의에도 어긋나지 아니한다.

셋째, 이러한 입법 작업 과정에서 독일 조직변경법(UmwG)의 Identitätsprinzip과 부동산취득세법(GrEStG) 제6a조가 조직법상 동일성과 부동산취득세 과세요건·비과세요건을 어떻게 연결하고 있는지를 참조함으로써, 조직법과 조세법의 연계를 통해 해석상 불확실성을 줄이는 모델을 검토할 필요가 있다.[52]

끝으로, 형법상 죄형법정주의·유추해석금지와 독일 조세법에서 논의되는 in dubio pro tributario 원칙, 그리고 "법문언의 가능한 의미(möglicher Wortsinn)"와 법형성 논쟁은, 조세법 해석에서 과세요건의 의미가 불명확하거나 상반된 해석 가능성이 병존하는 경우 그 모호성을 어떻게 처리해야 하는지에 관한 중요한 방법론적 시사점을 제공한다. 비법인사단의 법인전환과 취득세 과세요건 해석

52) 독일 조직변경법(UmwG) 제202조 제1항 제1호의 동일성 원칙(Identitätsprinzip)은 전환 전후의 법인이 법적으로 동일한 주체임을 명문화한다. 이에 따르면 형태전환(Formwechsel)은 기존 법인의 소멸과 새로운 법인의 설립이 아니라 동일한 단체가 법적 외형을 변경하는 절차로 이해되며, 자산과 부채는 이전이 아니라 동일 주체 내에서의 귀속 형식 변경에 불과하다. 나아가 GrEStG 제6조 내지 제6a조는 기업집단 내부의 조직 개편이나 형태전환에 수반되는 부동산 이전에 대하여 일정한 요건 하에 취득세를 부과하지 않거나 면제하는 특례를 두고 있다. 독일 연방재무법원(Bundesfinanzhof, BFH)도 이러한 입법 구조를 전제로, 조직법상 동일성이 유지되는 한 부동산취득세를 부과할 수 없다는 입장을 반복적으로 확인해 왔다. 이러한 비교법적 규율 방식은 비법인사단의 법인전환에 따른 부동산 이전을 둘러싼 현행 지방세법의 불명확성을 해소하기 위한 입법 모델을 모색하는 데 유의미한 참고 자료가 된다.

을 둘러싼 현재의 판례·실무 상황은, 바로 이러한 방법론적 논의가 요청되는 전형적인 사례라고 할 수 있다.

본고에서 제시한 “전환 전후 단체의 실질적 동일성이 유지되는 한 지방세법상 ‘취득’을 부정하는 해석론”과 이를 뒷받침하는 입법적 명확화 제안은, 형벌·조세 영역이 공유하는 법률주의 원칙과 해석상 긴장을 조세법 영역에서 구체화하려는 하나의 시도로 이해될 수 있을 것이다. 향후에는 조직형태 변경과 조세법률주의의 관계를 보다 폭넓은 비교법적 관점에서 검토하고, 다른 세목과의 체계적 정합성까지 고려한 해석·입법론을 추가로 모색할 필요가 있다.

참고문헌

〈국내문헌〉

곽윤직/김재형, 민법총칙(민법강의 Ⅰ), 9판, 박영사, 2013.

곽윤직/김재형, 채권각론(민법강의 Ⅳ), 6판, 박영사, 2022.

이창희, 세법강의, 22판, 박영사, 2024.

임승순, 조세법, 22판, 박영사, 2024.

권형기. “지방세법상 취득과 조세법상 차용개념에 대한 소고”, 조세와 법 제6권 제2호, 서울시립대학교 법학연구소. 2013.

권형기·고영우. “취득세의 '유통세적 성격'이 해석에 미치는 영향: 대법원 2018. 3. 22. 선고 2014두43110 전원합의체 판결과 취득세의 소비세적 성격을 중심으로”. 지방세논집 제9권 제1호, 한국지방세학회, 2022.

김민주. “비법인사단 관련 규정에 대한 소고-민법 제32조 허가주의와 제275조 이하 총유규정을 중심으로-”. 원광법학 제30권 제3호. 원광대학교 법학연구소. 2014.

김민호, “조세법에 있어 차용개념의 해석과 적용에 관한 연구 —조세회피행위 방지와 관련하여—”. 공법연구 제31집 제1호, 한국공법학회, 2002.

김상훈, “무상취득 관련 취득세 쟁점”, 지방세논집 제7권 제3호, 한국지방세학회, 2020.

김성균, “과세요건 명확주의 관련 개별 법령에 대한 고찰”, 공법학연구 제7권 제1호, 한국비교공법학회, 2006.

김성룡, “유추의 구조와 유추금지”, 법철학연구 제12권 제2호, 한국법철학회, 2009.

김성욱, “민법상 사단(社團)과 관련한 법적 문제”, 법학논총 제21권 제1호, 조선대학교 법학연구원, 2014.

김영순, “조세법률주의의 현대적 의미에 대한 소고—납세자의 예측가능성 보장 관점에서—”, 법학논총 제31권 제1호, 한양대학교 법학연구소, 2014.

김영환, “한국에서의 법학방법론의 문제점—법발견과 법형성: 확장해석과 유추, 축소해석과 목적론적 축소 간의 관계를 중심으로—”, 법철학연구 제18권 제2호, 한국법철학회, 2015.

문필주, “실질과세원칙 적용시 납세자 유·불리에 관한 판례의 현황과 그 분석”, 세무학연구 제35권 제3호, 한국세무학회, 2018.

박훈. “판례에 나타난 세법상 차용개념의 해석론”. 법조 제68권 제3호, 법조협회, 2019.

신만중, “취득의 개념과 부동산명의신탁”, 법학연구 제25권 제3호, 충남대학교 법학연구원, 2014.

오세혁, “법해석방법의 우선순위에 대한 시론적 고찰”, 중앙법학 제21집 제4호, 중앙법학회, 2019.

윤문구·문필주·박훈, “조세심판원 심판례 분석을 통한 취득세 취득개념의 해석론 및 입법론”, 경희법학 제55권 제1호, 경희대학교 법학연구소, 2020,

윤병철. “현물출자와 세법상 논점”, 조세법연구 제11집 제2호. 한국세법학회, 2005.

이계일, “우리 법원의 법률해석/법형성에 대한 반성적 고찰”, 법학연구 제25권 제4호, 연세대학교 법학연구원, 2015.

이재호, “세법상 유추의 可否에 관하여”, 조세법연구 제17집 제1호, 한국세법학회, 2011.

이중교, “주택재개발사업과 재건축사업의 취득세 과세에 대한 연구”, 공법연구 제37집 제1호, 한국공법학회, 2008.

이형규, “회사의 조직변경에 관한 입법론적 고찰”, 법조 제66권 제1호, 법조협회, 2017.
이혜진, “판례에 나타난 비법인사단의 유형 및 규율에 관한 입법론”, 동아법학 제71호, 동아대학교 법학연구소, 2016.
임상혁, “법인이 아닌 사단의 민사법상 지위에 관한 고찰—총유 규정을 둘러싼 민법 개정 논의와 관련하여—”, 서울대학교 법학 제54권 제3호, 서울대학교 법학연구소, 2013.
진상욱, “비법인사단의 총유물의 관리 및 처분”, 토지법학 제25권 제1호, 한국토지법학회, 2009.
최민수·박주영, “법인 아닌 사단과 총유규정에 관한 비판적 고찰—총유규정의 민법 개정안을 중심으로—”, 법학논총 제45권 제1호, 단국대학교 법학연구소, 2021.
최봉경, “민법에서의 유추와 해석—판례를 거울삼아—”, 법철학연구 제12권 제2호, 한국법철학회, 2009.
최성근, “실질과세원칙에 관한 법리와 규정에 대한 분석 및 평가”, 조세법연구 제19집 제2호, 한국세법학회, 2013.
최원, “취득세의 법적 성질론에 관한 소고—부동산에 대한 취득세를 중심으로—”, 세무학연구 제37권 제4호, 한국세무학회, 2020.
허완중, “조세법률원칙(조세법률주의)에 관한 헌법적 검토”, 법학연구 통권 제75집, 전북대학교 법학연구소, 2024.
황헌순, “헌법상 조세의 기본원칙과 세법상 실질과세”, 유럽헌법연구 제36호, 유럽헌법학회, 2021.

논문 투고일: 2026.04.30
심사 완료일: 2026.05.26
게재 확정일: 2026.06.10

[Abstract]

Acquisition Tax Liability upon Conversion of an Unincorporated Association into an Incorporated Association

Park Sang Young* · Kim Min Gyu**

When an unincorporated association converts into an incorporated association upon authorization by the competent authority and subsequently transfers the title of its real property to the new corporation, the question arises whether this transfer constitutes "acquisition" subject to acquisition tax under the Local Tax Act. This issue is not merely a technical matter of tax administration but directly implicates constitutional property rights and the principle of legality in taxation, given that acquisition tax on such transfers often involves very substantial financial burdens. In its decision of 24 November 2023, 2023Nu22276, the Busan High Court upheld the imposition of acquisition tax on the incorporated association, relying on three grounds: the characterization of acquisition tax as a circulation tax that captures the mere fact of transfer, the change from joint communal ownership of the members to sole ownership by the corporation as a change in the rights-holder, and the absence of any explicit statutory exemption for such transfers. By contrast, the Seoul Administrative Court, in its 2005 decision 2004Guhap17839, had treated the same type of transfer as a mere formality without a new acquisition where the essential identity of the association remains unchanged through the conversion.

This article first reconstructs the reasoning of the Busan High Court as a three-step syllogism-invocation of the circulation-tax doctrine, recognition of a change in the rights-holder, and reliance on the absence of an exemption provision-and evaluates each step in light of the principle of legality and clarity in taxation, the theory of borrowed legal concepts, and the civil-law structure of joint communal ownership in unincorporated associations. Rather than denying the circulation-tax nature of acquisition tax as such, the article argues that additional scrutiny is required when applying this general doctrine to atypical organizational transformations and that the Busan High Court failed to adequately examine whether there was a substantive change in the economic holder of the property. On this basis, the article advances a tentative interpretive thesis that where the essential characteristics of the unincorporated association are substantially maintained through the conversion process, the ensuing transfer of title should not be regarded as "acquisition" within the meaning of the Local Tax Act.

At the same time, the article contends that interpretive analysis alone cannot resolve the persistent uncertainty and divergence in lower-court decisions concerning such cases. It therefore proposes legislative reform of the Local Tax Act, either by explicitly excluding qualifying organizational conversions from the scope of taxable "acquisition" or by introducing a specific non-taxation or exemption provision for such transfers. Drawing on

* Master's student(Seoul National University School of Law)

** Attorney at Law, Adjunct Professor(KAIST Moon Soul Graduate School of Future Strategy)

German law, in particular the organizational continuity principle in the Umwandlungsgesetz and the special rules in §6a Grunderwerbsteuergesetz, the article explores how the linkage between organizational identity and the scope of transfer tax can be clarified at the statutory level. It concludes that treating title transfers accompanying the conversion of an unincorporated association into an incorporated association as non-taxable where organizational identity is preserved is more consistent with the principle of legality in taxation and systematic coherence and that legislative clarification is needed to reduce interpretive uncertainty and the risk of over-taxation in such cases.

KeyWord: Unincorporated association, Incorporated association, Corporate conversion, Acquisition tax, Joint communal ownership, Principle of legality in taxation, Prohibition of analogical interpretation, Substance-over-form doctrine, Borrowed legal concepts